

1502552-10.2020.8.26.0535

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... não gritou. Admitiu que responde por dois tráficos, um deles teve audiência em dia 21 de setembro. Acrescentou que tem mais um outro tráfico e este que está respondendo. Noticiou que o tráfico anterior estava dentro do mato, tinha um pouco de droga, os mesmos policiais o prenderam. Asseverou que recorda do Wanderci, ele fica andando de um lado para o outro, já o viu na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1502552-10.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502552-10.2020.8.26.0535

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO MOREIRA DOS SANTOS e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

LEANDRO CÉSAR CARDOSO, DIEGO MOREIRA DOS SANTOS e WANDERCI ARRUDA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 33, caput e artigo 35 da Lei nº 11.343/06, pois, desde data incerta, antes do dia 11 de dezembro de 2020, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Consta, ainda que no dia 11 de dezembro de 2020, às 20 horas, na Rua Arnaldo Afonso De Lima, nº 167, Bairro Nossa Senhora Carmo, nesta cidade e comarca de Arujá, os acusados traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 34 porções de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecido como "maconha", pesando 38,02 (trinta e oito gramas e dois decigramas), e uma pequena porção de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecido como "maconha", pesando 11,64g (onze gramas e sessenta e quatro decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a exordial acusatória, no dia 11 de dezembro de 2020, policiais militares receberam denúncia de que no local dos fatos havia um indivíduo de terno, que entregou uma sacola contendo drogas para um indivíduo com uma camiseta de time de futebol, o qual estaria realizando a traficância.

Os policiais então se dirigiram ao local dos fatos, uma viela que liga a antiga Rua quatro com a antiga Rua três, por isso, antes de chegarem ao local o policial William desembarcou da viatura e seguiu a pé pela Rua Quatro, enquanto o policial Nilton seguiu de viatura pela Rua Três e, ao se aproximar da viela visualizou,

Diego, Wanderci, Renan e Leandro que estava um pouco afastado, e ao perceber a presença da viatura começou a gritar “molhou, molhou”, os quatro indivíduos saíram correndo em direção à Rua Quatro.

Diante da tentativa de fuga, o policial Nilton desembarcou da viatura e começou a correr pela viela, momento em que o policial William acessou a mesma viela no sentido contrário e deu ordem de parada a Diego, Wanderci, Renan e Leandro, entretanto, Diego continuou a correr em direção do policial William, e ambos acabaram entrando em luta corporal, somente no momento em que o policial Nilton conseguiu alcançá-los é que Diego foi contido e algemado, contudo, para tanto, foi necessário o uso de força moderada.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Renan, o qual informou ser usuário de drogas, e estava no local com o intuito de adquirir as substâncias para seu consumo, no entanto, antes mesmo que pudesse ter comprado a droga a viatura chegou ao local e ele decidiu correr com os outros indivíduos.

Com Diego, o indivíduo que vestia uma camiseta de time, foi encontrado no bolso de sua blusa a quantia de R\$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais) e no interior da sacola plástica que estava em suas mãos, foram localizadas 34 porções de maconha, ele admitiu aos policiais que estava no local praticando o tráfico de drogas e os valores localizados em sua posse eram fruto das vendas que teria realizado naquela data.

Com Wanderci, indivíduo que estava de terno, foi localizado em seu bolso uma pequena quantidade de maconha, a qual não estava embalada, ele disse que estava no local para levar uma sacola a Diego, a pedido de uma terceira pessoa que não estava ali, disse ainda, que era apenas usuário de drogas.

Leandro admitiu aos policiais que sua função naquele local era a de olheiro, e que para isso receberia a quantia de R\$ 30,00 (fls. 161/164).

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 11/16). Laudos periciais (fls. 21/26 e 145/152). Folha de antecedentes (fls. 101/109).

Em análise da prisão em flagrante dos réus Diego e Leandro, esta foi convertida em prisão preventiva (fls. 122/124).

Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 167, 168 e 235/237).

Foi concedida liberdade provisória ao réu Diego (fls. 190/194), com cumprimento do alvará de soltura em 26/03/2021 (fls. 211).

Foi recebida a denúncia em 25/06/2021 (fls. 254/255).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e ao final interrogados os réus (fls. 308/313).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e postulou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. Na dosimetria pleiteou a fixação da pena-base no patamar mínimo. Na segunda fase nenhum dos réus deve ser beneficiado com a atenuante da confissão. Na terceira fase pleiteou a não aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, por se dedicarem os réus à atividade criminosa, já tendo Leandro e Diego sido presos posteriormente pela prática do mesmo crime. Pugnou pela aplicação do regime fechado (fls. 313).

A defesa dos réus Leandro e Diego alegando a fragilidade da prova emanada da palavra dos policiais. Sustentou que o réu Diego confessou a traficância, tendo-o feito em solo policial, não o fazendo apenas para inocentar os demais réus como alegou o Ministério Público. Destacou que não ficou comprovado que Leandro portava qualquer entorpecente. Apontou que o réu Diego foi agredido pelo policial William. Requerer a aplicação do in dubio pro reo e pleiteou a absolvição dos réus (fls. 316/332).

A defesa do réu Wanderci pugnou pela absolvição do réu. Sustentou que o acusado nunca praticou o comércio espúrio, tratando-se de episódio isolado e inverídico. Argumentou que os demais acusados admitiram que não conheciam Wanderci e que este era um andarilho ou morador de rua. Alternativamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo, com aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 339/354).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, laudo toxicológico, demais documentos e prova oral produzida.

A autoria segue a mesma sorte em relação a um dos acusados.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha José Nilton, policial militar, relatou que faz um bom tempo que aconteceram os fatos, mas se recorda vagamente. Disse que foi uma ocorrência irradiada via Copom de que um indivíduo estava levando drogas para a biqueira. Externou que a biqueira é o local onde fazem o comércio das drogas. Afirmou que como o depoente e seu parceiro estavam próximos ao local, o depoente deixou seu parceiro na Rua Quatro e deu a volta com a viatura pela Rua Três, fazendo um cerco de uma viela entre a Rua Três e a Rua Quatro. Contou que quando adentrou a Rua Três o Leandro, que estava mais à frente, gritou na gíria deles, tipo "molhou, molhou, a polícia chegou", e ambos saíram correndo a viela sentido a Rua Quatro, indo de encontro ao parceiro do depoente. Externou que desembarcou da viatura e correu atrás deles, seu parceiro deteve três, somente um resistiu, que foi o Diego, que entrou em luta corporal, e o depoente acabou alcançando e ajudou a contê-lo. Acrescentou que Diego trazia a sacola com as drogas. Apontou que diante dos fatos foi dada voz de prisão, encaminhada ao PS e apresentada a autoridade de plantão. Disse recordar de um senhor de terno, era o Wanderci, a denúncia foi recebida antes. Mencionou que Wanderci foi um dos que correram a viela sentido a Rua Quatro. Complementou que antes não foi visualizada negociação ou Wanderci indo e vindo, apenas o visualizou na ponta da viela, não tinha nada nas mãos dele, só na mão do Diego tinha uma sacola. Noticiou que conforme o histórico do BO foram 34 porções de maconha e tinha lança perfume também, mas não recorda a quantidade, porque estava espalhada na viela, conforme eles correram acabaram deixando cair no chão.

A testemunha Willian, policial militar, relatou que foi uma ocorrência despachada via Copom, no bairro Parque Rodrigo Barreto. Disse que no dia dos fatos assim que receberam a denúncia estava próximo nos arredores. Contou que se deslocou para atender a ocorrência, tinha indivíduos referenciados, mas como o local era uma viela utilizada como rota de fuga, o depoente desembarcou na rua a pé, enquanto seu companheiro deu a volta para fazer o cerco. Complementou que a viatura fez com que os indivíduos corressem em direção ao depoente afunilando pela viela. Disse que conseguiu abordá-los, um deles tentou resistir, entrou em luta corporal, o depoente o segurou até a chegada de seu parceiro, então fizeram o algemamento dele. Noticiou que encontraram droga e dinheiro com eles e todos foram conduzidos até a delegacia. Mencionou que na denúncia constava um senhor de avançada idade, que estava bem vestido, mas com ele foi encontrada uma quantidade de entorpecentes escondida nas partes íntimas. Disse não recordar de ter visualizado a entrega, a denúncia narrava que um senhor de terno estaria levando droga para a biqueira. Falou que não consegue apontar quem estava com a sacola da droga. Pontuou que com o Wanderci tinha apenas uma porção de entorpecentes, não tinha mais nada com ele.

O réu Leandro disse que tem 31 anos, trabalha como ajudante geral, motorista e logística, estudou até o segundo ano do colegial, não é casado e não tem filhos, já foi processado antes por tráfico de drogas e não foi condenado. Afirmou que saiu de sua casa por volta de 18h da tarde e foi em direção ao ponto de tráfico, a intenção era comprar droga e seguir caminho, mas chegando lá foi abordado pelas viaturas. Acrescentou que inclusive há câmeras no local que comprovam o horário que o depoente passou. Mencionou que no local tinha um burburinho de gente e em volta tinham umas oito pessoas, e elas saíram correndo. Aduziu que conforme o relato do policial foi apreendido um pouco mais distante, isso porque tem uma fratura na coluna que o impede de correr. Observou que saiu andando e quando chegou lá na frente, os policiais abordaram todo mundo, não tinha droga e nem dinheiro, mas foi preso. Comentou que foi preso antes, responde por reincidência, por algo que não cometeu, inclusive por ser negro e pobre e estar naquele lugar praticamente

condena. Frisou que não conhecia ninguém e não teve contato anterior ou no dia seguinte, o negócio foi na hora, foi vítima de abordagem e acabou sendo preso. Falou que tinha dinheiro, cinco reais, uma bíblia de bolso e um eppendorf vazio. Disse que na hora que os policiais chegaram não gritou. Admitiu que responde por dois tráficos, um deles teve audiência em dia 21 de setembro. Acrescentou que tem mais um outro tráfico e este que está respondendo. Noticiou que o tráfico anterior estava dentro do mato, tinha um pouco de droga, os mesmos policiais o prenderam. Asseverou que recorda do Wanderci, ele fica andando de um lado para o outro, já o viu na rodoviária, inclusive ele toma conta de carros, mas não estavam juntos na data dos fatos. Pediu que o depoimento seja analisado detalhadamente, teve a sorte infeliz de procurar a droga.

O réu Diego disse que tem 20 anos, trabalha com funilaria e pintura, ganhava R\$ 250,00 por semana, estudou até o primeiro colegial, é casado e tem um filho, já foi processado por associação. Relatou que realmente estava no local vendendo há duas semanas, recebeu a proposta de um rapaz que trabalhava na biqueira, ele o chamou, e como estava precisando devido a pandemia e por causa do filho novo resolveu arriscar, mas se arrependeu. Externou que o Leandro e o Wandeci apenas estavam lá. Apontou que sobre o lança perfume que o policial falou é mentira, mas a maconha e o dinheiro realmente foram encontradas. Contou que no começo estava dando certo, estava conseguindo levar comida para dentro de casa, ajudar sua mãe e seus filhos. Falou que na sexta-feira pegou uma quantidade de maconha, foi vender para o rapaz que diz ser gerente, ele deu uma quantidade de maconha e disse para vender até 19h, e que nesse horário viria pegar o dinheiro, pagar o depoente, que depois poderia ir embora. Comentou que umas 18h tinha pessoas e avistaram a polícia. Observou que os policiais desceram a rua de viatura e na ponta da viela avistaram outro policial, alguém gritou "molhou", então saiu correndo com a sacola no bolso. Disse que tinha o depoente e o Leandro, o Wanderci não estava, ele chegou depois, e tinha mais duas pessoas. Comentou que na delegacia confessou tudo e já assumiu, então os outros foram liberados, ficaram só o depoente e o Leandro preso. Explanou que naquela hora saiu correndo, não chegou a agredir o policial, só pediu para ele soltar, ele veio, bateu, deu um soco na cara, inclusive até atirou. Pontuou que fizeram a prisão e foram para o pronto socorro, fizeram curativo em seu rosto, o pegaram e levaram até a delegacia. Noticiou que quando pegou o saco tinha 38 porções, mas no meio da confusão perdeu e ficaram 34 porções. Afirmou que o Leandro estava apenas olhando a rua, ele ia comprar com o depoente, mas quando os policiais vieram todo mundo gritou "molhou" e saiu correndo, só que o Leandro não consegue correr, ele ficou parado, e os policiais pensaram que ele ficou campanando. Disse que sabe que Leandro não pode correr por ele ter uns problemas nas costelas, pois já conhecia o Leandro há alguns dias e ele contou que tinha problemas de coluna. Narrou que Leandro não tem "nada a ver" e assumiu. Disse que nunca tinha vendido antes drogas na sua vida. Afirmou que Wanderci chegou dentro da viatura quando os policiais mandaram que ele entrasse na portaria. Os policiais lhe falaram que "o andarilho" entregou tudo, mas não conhecia Wanderci e ele apareceu na biqueira na hora que a polícia chegou. Disse que os policiais falaram que pegaram Wanderci numa praça e trouxeram ele. Disse que vendia cada porção de uma grama por R\$ 5,00. Ganhava R\$ 60,00. Contou que antes de chegar no local o vulgo "neguinho" estava vendendo drogas no local, mas ele estava durante o dia. Chegou e comprou uma "paranga" com neguinho. Depois ele ofereceu que ele vendesse a droga e começou a vender a droga às 15 horas. Foi a primeira vez que Leandro ia comprar a droga com o depoente. Não tinha "olheiro" na data dos fatos e não sabe quem gritou "moio". Na hora dos fatos estava o depoente, Leandro, Renan e mais dois caras que fugiram. Mencionou que uns queriam pó e pedra, mas estava somente vendendo maconha. Disse que foi novamente preso por tráfico em Bragança.

O réu Wanderci Arruda declarou que tem 58 anos, trabalha como ajudante de pedreiro e ganha em torno de R\$ 800,00 por quinzena, estudou até 5ª série, é amigado e tem um casal de filhos, sendo um deles menor de idade, já foi processado antes por roubo, sendo condenado, o que aconteceu há muitos anos. Disse que é usuário de drogas e estava com uma porção, descendo para a viela. Acrescentou que ia usar drogas em local ermo e uns rapazes tinham porções de drogas, mas não iria encontra-

los. Frisou que sua porção de droga era para consumo próprio. Salientou que ao descer a viela o policial perguntou se tinha droga e o depoente confirmou que tinha, então ele o pegou. Falou que os policiais prenderam os rapazes. Explicou na delegacia que a droga era sua e a droga dos rapazes pertencia a eles. Disse que na delegacia o Delegado falou que estava sendo acusado como traficante e perguntou se os policiais o tinham agredido e o que estava fazendo com a droga, respondendo o depoente que ia usar em um lugar ermo. Salientou que tinha uns 15 ou 20 pacotes para usar, o suficiente para enrolar um cigarro. Disse não recordar se estava de terno na data dos fatos.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ao cabo da instrução processual, restou demonstrada a prática do delito de tráfico de drogas pelo réu Diego, impondo-se, no entanto a absolvição dos réus Leandro e Wanderci do crime que lhe fora imputado na denúncia, como será melhor explanado adiante.

Antes, porém, impõe-se absolver os réus no tocante ao crime de associação para o tráfico.

Isto porque, não restou devidamente demonstrado no caso em tela a prática do delito de associação para o tráfico, eis que os elementos probatórios são insuficientes à certeza de sua ocorrência.

Como é cediço, o crime do art. 35 da lei 11.343/2006 é uma espécie de quadrilha ou bando específico do tráfico ilícito de entorpecentes, exigindo para a sua configuração a comprovação de sua permanência. Afirma Guilherme de Souza Nucci (2009, p.365):

“Demanda-se prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa.” E mais: “exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no animo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática de crime de tráfico.”

No caso em testilha, não tendo sido comprovado o caráter de estabilidade e permanência da associação, não há como se imputar aos acusados a prática do crime em questão, não tendo, desta feita, se desincumbido o Ministério Público do ônus probandi que lhe é imposto.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça:

Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343.2006”. (HC 349837/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, v.u., j. 03.05.2016. No mesmo sentido REsp 1501842/PR, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, v.u., j. 05.04.2016).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE APONTAVAM NOMINALMENTE AS PESSOAS DOS RÉUS COMO TRAFICANTES - APREENSÃO DA DROGA EM LOCAL PRÓXIMO - ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RECURSO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 - POSSIBILIDADE. - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso, mostrando-se hábeis, portanto, a confirmar os fatos expostos no flagrante e comprovar a autoria delituosa. - Tendo os policiais recebido denúncia anônima apontando as pessoas dos réus como traficantes, e sendo eles abordados em lugar conhecido como ponto de venda de drogas, apreendida em local próximo elevada quantidade de entorpecentes, deve ser mantida a condenação. - Para caracterização do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06, deve ser comprovada a estabilidade e permanência do vínculo associativo, não demonstradas no presente

caso, mantendo-se a absolvição declarada na sentença. (TJ-MG - APR: 10079073229183001 MG , Relator: Delmival de Almeida Campos, Data de Julgamento: 15/05/2013, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2013, undefined)

Como mencionado alhures, mesmo que entendêssemos estarmos diante de alguns indícios de associação, isso não deve bastar para caracterizar a culpabilidade dos réus pelo delito em questão, especialmente quando toda a investigação não veio acompanhada de uma apuração mais rigorosa destas circunstâncias.

No caso, pode-se até cogitar de probabilidade do crime de associação, mas o fato é que, "no processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio." (RT 619/267).

Outrossim, para configuração do delito de associação não se exige que os componentes da associação se conheçam e que haja nítida divisão de funções. Basta, apenas, que a associação vise à prática de um número incerto de crime, por tempo indeterminado (elemento subjetivo do tipo). No caso dos autos, todavia, a presença de vínculo estável e psicológico entre os agentes não restou evidenciada pelas provas produzidas.

Registre-se que não houve investigação prévia sobre a atuação dos acusados ou mesmo posterior que pudesse confirmar o vínculo associativo descrito na exordial acusatória. Ademais, os próprios réus, à sua maneira, negaram a associação.

Ainda, não foram encontrados com os acusados anotações, balança ou outros insumos que pudessem revelar ou confirmar uma ligação estável e permanente entre eles para prática reiterada de crimes, nem mesmo de tráfico.

Quanto ao delito de tráfico, como já referido alhures, a conclusão é diversa, havendo elementos aptos a impor a condenação do réu Diego, o que, todavia, não se aplica aos réus Leandro e Wanderci.

Os laudos periciais comprovam a natureza da droga encontrada, indicando que o material apreendido consistia de fato em cocaína, droga com maior poder vulnerante. O depoimento das testemunhas policiais é uníssono e coeso ao indicar que foram encontradas drogas com Diego, o qual também terminou por confessar a prática delitiva tanto em solo policial quanto em Juízo, tendo admitido a prática do comércio espúrio na ocasião dos fatos da abordagem policial.

O flagrante em relação a Diego é inquestionável, e as palavras dos policiais, nesse ponto, são suficientes, haja vista que estão em conformidade com as demais provas dos autos, mormente ante a versão confessional apresentada pelo réu Diego.

É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, é construída com base nos depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos.

E no caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e idôneo para o reconhecimento da culpabilidade do réu Diego, porque ao lado dos depoimentos policiais, há a apreensão do entorpecente onde estava o acusado, circunstância que não foi por este negada.

Inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente o réu de pena.

No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

O desfecho dos autos com relação aos réus Leandro e Wanderci, todavia, é distinto. Segundo consta dos autos, nada de ilícito foi encontrado com Leandro na ocasião da abordagem, sendo dito apenas pelos policiais que sua função naquele local era a de olheiro.

Ocorre que em Juízo os policiais José Nilton e Willian disseram que nada foi encontrado com Leandro, nem sequer avistaram o mesmo realizando a prática do

comércio espúrio, apenas na mão de Diego havia uma sacola com drogas. Além disto, em solo policial o réu Leandro rechaçou tal hipótese de que seria olheiro, asseverando com veemência que foi até o local a fim de comprar drogas para consumo pessoal, tendo relatado que comprou um eppendorf de crack e logo o consumiu, salientando que na ocasião da abordagem foi localizado em seu poder tão somente o eppendorf vazio.

Em Juízo, o réu Leandro apresentou relato semelhante, dizendo que a intenção era comprar droga e seguir caminho, tendo negado também que gritou na ocasião ou que permaneceu parado no local a fim de avisar os demais sobre a chegada dos policiais. Neste ponto, não passa desapercibido que o réu Leandro justificou que não correu quando da chegada da polícia porque teria problemas na coluna, o que foi também mencionado pelo réu Diego em seu depoimento.

Não tendo sido apreendida droga em poder do acusado Leandro, bem como inexistindo maiores indícios de sua participação efetiva no comércio espúrio, torna-se inviável a sua condenação.

Isto porque, pela prova colhida nos autos, não há certeza de que o réu possuía drogas para fins de tráfico. Efetivamente nada há que assegure, com a certeza necessária, que o réu exercia tráfico de entorpecentes, mormente porque não se visualizou nenhum ato de traficância.

Já no tocante ao réu Wanderci, vê-se que é indivíduo idoso, de 59 anos de idade (nascido em 14/12/1962), não havendo nos autos registro de que tenha antecedentes criminais ou mesmo qualquer passagem anterior, haja vista não ter sido juntada ao feito a folha de antecedentes.

Ressalte-se que o réu Wanderci sequer foi mantido preso durante o trâmite processual, sendo liberado de imediato pela própria Autoridade Policial que enquadrou sua conduta como figura típica do delito de uso de drogas, senão vejamos: Já em relação ao autor Wanderci, em que pese os policiais tenham dito que ele teria confessado que levou uma sacola e retiraria o dinheiro do local, em busca pessoal, apenas uma porção de maconha foi localizada com ele, a qual, segundo suas declarações, tentaria trocar por uma pedra de crack para seu consumo pessoal. Por isso, entendo que sua conduta se amolda à figura típica do artigo 28 da lei 11.343/06, tendo sido o mesmo liberado mediante assinatura do termo de compromisso da lei 9.099/95 (fls. 16).

No que diz respeito a Wanderci, segundo consta na inicial acusatória, seria ele supostamente o indivíduo de terno objeto da denúncia que estaria entregando drogas na biqueira, sendo localizada em seu bolso na abordagem uma pequena quantidade de maconha, tendo dito aos policiais que era usuário de drogas.

De fato consta nos autos uma fotografia, muito provavelmente tirada na ocasião da apreensão de Wanderci (fls. 17), onde se observa que está vestido com camisa de time de futebol nacional e calça esportiva azul, trajando ainda um paletó, aparentando ser de fato um andarilho como se fez menção durante as oitivas.

Em Juízo o policial José Nilton disse recordar de um senhor de terno, complementando que antes da abordagem não foi visualizada negociação ou movimentação de Wanderci, bem como que nada havia nas mãos dele.

Já o policial Willian disse que na denúncia constava um senhor de avançada idade, que estava bem vestido, mas com ele foi encontrada uma quantidade de entorpecentes escondida nas partes íntimas, entretanto disse não recordar de ter visualizado a entrega, e a denúncia narrava que um senhor de terno estaria levando droga para a biqueira. Pontuou que com o Wanderci tinha apenas uma porção de entorpecentes, não tinha mais nada com ele.

Em solo policial Wanderci afirmou que é usuário de crack e um conhecido lhe presenteou com uma porção de maconha, mas como não consome esse tipo de drogas foi até a viela para trocar a maconha por uma pedra de crack. Admitiu que durante a revista o policial localizou a porção de maconha que estava em suas vestes.

E em Juízo Wanderci disse que é usuário de drogas e estava com uma porção e ia usar os entorpecentes em local ermo.

Nessa esteira, verifica-se que em poder de Wanderci foi encontrada apenas e tão somente uma pequena porção de drogas, o que somado ao relato dos policiais e do próprio réu resulta na conclusão de que se trata, muito provavelmente, de mero

usuário de drogas, como também interpretou a Autoridade Policial na ocasião da lavratura do Boletim de Ocorrência.

A acusação aponta ainda a existência de denúncia anônima, no sentido de que um indivíduo de terno estaria entregando drogas na biqueira, como narrou um dos policiais. Não obstante, aos autos não foi juntada qualquer comprovação da existência da referida denúncia anônima e de seu teor, ou qualquer documento que ateste o seu registro.

Ainda, não há notícias de realização de qualquer campana e os policiais afirmaram, apenas, que ao realizar a operação encurralaram os abordados na viela e passaram então a abordá-los.

Como sói ocorrer, não foi trazida qualquer outra testemunha, como outro frequentador do local em que estavam os acusados, que estivesse presente no momento do flagrante, mesmo havendo relato de tratar-se de ponto de venda de droga, sendo certo, neste caso, que havia outros indivíduos no local, inclusive Renan, que foi ouvido em solo policial, mas não foi trazido a depor em Juízo.

É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos, como já salientado. A presente situação não se amolda, todavia, a esta regra, lembrando que o réu Leandro negou a titularidade da droga descrita na denúncia e o comércio espúrio, ao passo que o réu Wanderlei confirmou apenas que portava droga para fins de consumo pessoal, não havendo, do mesmo modo, outros indicativos seguros da ocorrência de tráfico de drogas por parte de tais réus.

Não se trata aqui, de forma alguma, de desqualificar todo e qualquer testemunho prestado por policiais, mas de manter-se o julgador atento a possíveis falhas perpetradas por estes no exercício de sua função, que podem até incluir imputações precipitadas, pouco apuradas, apressadas.

Nessa toada, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - NECESSIDADE - PALAVRA ISOLADA DOS POLICIAIS. A versão policial isolada sobre a prática do crime não forma conjunto probatório suficiente para sustentar a convicção sobre a destinação da droga apreendida e, portanto, não autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.16.010381-7/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018).

Neste sentido também é o ensinamento de Gustavo Badaró:

Quanto ao testemunho dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do artigo 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma posição intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelos simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por ele investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se demonstrem harmônicos entre si (BADARÓ, Gustavo Henrique; Processo Penal. São paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 477/478). (Grifos nossos)

Em sentido semelhante ao aqui exposto, esclarece, de forma muito didática, Aury Lopes Jr:

Da mesma forma, não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.

Contudo, é recorrente o Ministério Público arrolar como testemunhas apenas os policiais que participaram da operação e da elaboração do inquérito. Busca, com isso, judicializar a palavra dos policiais para driblar a vedação de condenação “exclusivamente” (art. 155 do CPP) com base nos elementos informativos colhidos na investigação. Na continuação, deparamo-nos com sentenças condenatórias em que são utilizados os elementos do inquérito e o depoimento dos policiais em juízo. No fundo, é um golpe de cena, um engodo, pois a condenação se deu, exclusivamente, com base nos atos da fase pré-processual e no depoimento contaminado de seus agentes, natural e profissionalmente comprometidos com o resultado por eles apontado, violando o disposto no art. 155 do CPP. Portanto, se não há impedimento para que os policiais deponham, é elementar que não se pode condenar só com base nos seus atos de investigação e na justificação que fazem em audiência.” (2019, p.462)

Aliás, na linha do que está sendo exposto, se a ideia fosse tomar como absoluta e incontestável toda e qualquer declaração prestada por testemunhas policiais no bojo do processo penal, despicienda seria a instrução probatória e até mesmo a valoração da prova colhida pelo Juiz de Direito.

Outrossim, como este juízo sempre vem asseverando, não é demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a reunião de outros elementos probatórios que não se limitem à mera repetição das declarações dos policiais que efetivaram a prisão do acusado, até porque, como consignado alhures, é natural que estes objetivem legitimar, até inconscientemente, sua própria atuação. Aliás, não se pode deixar de registrar, em crimes de natureza diversa do ora apurado, ao lado dos depoimentos policiais, são em regra produzidos outros elementos de prova, a exemplo de testemunhos de terceiros, oitiva da vítima, com reconhecimento de pessoa e de objeto, etc, o que sem dúvida contribui para a realização de uma instrução processual mais robusta, com possibilidade de uma construção mais sólida da culpabilidade do agente.

Por um outro viés, estes mesmos policiais já dispõem, nos dias atuais, de outros instrumentos e mecanismos aptos a robustecer os motivos ensejadores da prisão e da persecução penal, conferindo às suas declarações um caráter de veracidade quase irrefutável, como já se pôde constatar em outras oportunidades, em que os policiais se valeram, inclusive, de gravações audiovisuais para registrar as abordagens, diligências e operações.

Assim, a despeito da probabilidade da ocorrência do tráfico de drogas e mesmo que se considere pouco crível a versão apresentada pelos réus, o conjunto probatório produzido não se mostra firme o bastante para lastrear uma condenação por tráfico de drogas pelos acusados.

Destarte, nesta fase processual, encerrada a instrução, se alguma dúvida existe deverá ser interpretada em favor dos réus, conforme recomenda a boa técnica processual penal.

No mais, conforme leciona o Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 150 ), membro do Ministério Público de São Paulo:

“A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de condenar quem nada deva.

Quando se tem presente, salientou Malatesta, que a condenação não pode basear-se senão na certeza da culpabilidade, logo se vê que a credibilidade razoável – também mínima – da inocência, sendo destrutiva da certeza da culpabilidade, deve, necessariamente, conduzir à absolvição”.

Com efeito, uma sentença judicial condenatória deve ser embasada em elementos objetivos, contundentes e sólidos. Em verdade, para fins de condenação criminal, a intuição desde julgador não tem qualquer importância. Não basta a crença, deve haver certeza.

Em casos de dúvida, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição dos acusados como medida de justiça.

Sobre a presunção de inocência, manifesta-se Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2008, p.178/19):

“...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos.”

“Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo”.

Assim, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade.

A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi autor do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão.

Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque:“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

Novamente, colaciona-se o escólio do Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 15):

A respeito, obtempera Heleno Cláudio Fragoso que "a condenação exige certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de nossa mente em torno da existência de certa realidade". Mesmo a íntima convicção do Juiz - pondera Sabatini -, como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação (g.n.), não é verdadeira e própria certeza (...); no lugar da certeza, em espécie tal, tem-se a simples crença.

O entendimento do nobre membro ministerial é de rara sabedoria e desmerece contestações.

Nesse contexto, no caso em tela, diante do teor do interrogatório dos acusados Leandro e Wanderci, das inconsistências apontadas e havendo apenas os testemunhos policiais que são a exata reprodução das declarações que constam em inquérito, considerando que os elementos amealhados no curso da instrução penal não permitem concluir com segurança necessária que os acusados praticavam o crime inserto no art. 33 da lei 11.343/06, impõe-se, com isso, a absolvição do réu Leandro, e a desclassificação da conduta do réu Wanderci para porte para uso próprio, já que para tanto há elementos suficientes.

Com efeito, o réu Wanderci todo o tempo alegou que estava no local dos fatos para adquirir a droga para seu uso. Do mesmo modo fez o réu Leandro, a diferença, no entanto, reside na circunstância de ter sido localizada a droga em poder de um e do outro não.

Isto é, com Leandro, não se localizou droga, e a despeito de ter ele confirmado que estava no local para consumir entorpecentes, tendo-o feito momentos antes da abordagem, tal confissão aliada a ausência de localização de drogas em seu poder resulta na absolvição, como já pontuado alhures.

Já Wanderci confirmou que portava drogas para fins de uso, sendo tais drogas localizadas pelos policiais na ocasião da abordagem, e concluído a Autoridade Policial que se tratava de típico delito de uso de drogas.

De todo modo, mesmo que se entendesse que o réu Wanderci faltou com a verdade quanto à titularidade da droga apreendida - o que já se viu, não está devidamente comprovado, lembrando que a maior parte das drogas apreendidas não foram efetivamente localizadas com o réu, mas sim com o acusado Diego - fato é que, objetivamente falando, a quantidade de drogas localizada, a despeito da forma em que organizada, não é grande, considerando a massa (11,64g), não sendo suficientemente a atestar isoladamente, ao menos em tese, a prática de tráfico. É de sabença geral que os entorpecentes apreendidos são viciantes e que usuários podem fazer uso de diversas porções num mesmo dia. Ainda, não raras vezes, os usuários, de forma a evitar a compra fracionada da droga, optam por adquiri-la em quantidade maior, para uso futuro e prolongado.

Outrossim, a diversidade de drogas não obsta que o agente seja reconhecido como mero usuário, sendo comum que usuários utilizem mais de um tipo de entorpecente. A propósito, tratando acerca da possibilidade de quantidade razoável de drogas não obstar a desclassificação para o crime de porte para uso próprio, os arestos abaixo colacionados:

Tráfico e posse ilegal de arma (artigos 12 da Lei Antitóxicos e 10 da Lei nº 9.437/97) - Apelo que visa apenas e tão-somente à desclassificação do crime de tráfico para uso próprio - Admissibilidade - Apreensão de razoável quantidade de maconha em poder do acusado (cerca de 200 gramas) que não induz, por si só, traficando - Acusação que não se desincumbiu de provar, à sociedade, o destino comercial da droga - Réu dependente, tendo inclusive sua capacidade diminuída em razão do excessivo consumo, conforme atestaram os peritos - Justificativa razoável dada pelo réu, e confirmada por testemunhas, quanto ao destino dos saquinhos tipo uchip-chupf' encontrados em sua residência (eram utilizados pela mãe para fazer sorvete) - Recurso provido. (TJSP, 0074623-07.2001.8.26.0000 Apelação Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Relator(a):Walter de Almeida Guilherme, Órgão julgador:3ª Câmara de Direito Criminal, Data de registro:28/03/2003).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. 1. A quantidade de droga não é, por si só, suficiente para embasar uma decisão condenatória por tráfico de entorpecentes, mormente pela espécie apreendida. Ausentes outros indícios da destinação comercial da droga, e razoável a tese defensiva suscitada pelo réu, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente desclassificação da conduta para os limites do artigo 28 da Lei 11.343/06. No caso concreto, as testemunhas afastaram a tese da traficância, na medida em que ausente qualquer movimentação nesse sentido, na residência do imputado, local onde não foram localizados quaisquer vestígios da imputação incoativa. A afirmação foi de nunca terem notado nenhuma movimentação no local a indicar ser o réu traficante; não terem identificado nenhuma movimentação compatível com a comercialização de drogas e que a balança, de ponteiros, era utilizada para pesar porco e galinha, animais criados e vendidos como forma de complementação de sua renda. Os próprios policiais afirmaram não terem encontrado, na casa do réu, nenhum indicativo de comercialização de drogas. 2. Não basta, para a adequação típica de um dado fato ao tipo penal de receptação, a simples apreensão do objeto furtado com o réu. É imprescindível, também, a demonstração inequívoca do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, a comprovação do dolo do agente, de saber ele que o objeto adquirido era produto de crime. No caso concreto, nada foi produzido nesse sentido. Decisão absolutória mantida, nesse aspecto. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. POR MAIORIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70038726964, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 14/10/2010).

Tráfico. Condenação. Desclassificação. Procedente. Insuficiência de prova quanto à traficância. Pequena quantidade de droga encontrada aliada à ausência de prova. Remessa dos autos ao Jecrim. Impossibilidade. Princípios da celeridade processual, identidade física do juiz, bem como por prevenção. Extinção da punibilidade. O réu encontra-se preso provisoriamente há, aproximadamente, 3 meses. Detração. Negado Provimento. De ofício, extinta a punibilidade. (Relator(a): Guilherme de Souza Nucci; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 30/08/2011; Data de registro: 12/09/2011; Outros números: 990090347163)

Conforme constou do acórdão:

Em que pese a versão pouco crível trazida pelo apelado, é certo que não há nos autos provas suficientes a atestar, de forma inequívoca, a intenção da traficância, sobretudo ao considerar a ínfima quantidade de droga encontrada em poder do denunciado. Ou seja, se por um lado o apelado não trouxe à lume uma versão consistente a comprovar, ao menos, ser usuário de droga, por outro lado o membro acusatório, juntamente com a autoridade policial, não obtiveram sucesso em demonstrar a finalidade de traficância, panorama esse o qual circundado pelo princípio do in dubio pro reo, solução não resta ao Poder Judiciário a não ser desclassificar a conduta para porte de droga para consumo próprio. O único elemento concreto, apesar das negativas do apelado, reside no fato dos entorpecentes estarem em seu poder, consoante depoimento dos policiais militares (parte do voto de Guilherme de Souza Nucci, que consta acórdão supra mencionado).

Assim, considerando em especial o contexto do flagrante, a insuficiência probatória, as circunstâncias e inconsistências apontadas, inviável é a condenação do réus Leandro e Wanderci pelo tráfico, sendo, de todo modo, cabível, sobretudo diante da admissão de que se tratava de usuário e que estava no local para comprar droga, tendo inclusive adquirido uma porção, a condenação de Wanderci pelo delito inserto no art. 28 da lei 11.343/06.

Neste escopo, é possível o imediato julgamento do feito, sendo desnecessário o envio dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Ressalto que não há nenhum prejuízo ao réu pelo não oferecimento da proposta de suspensão condicional a ele, uma vez que a condenação prévia por porte de drogas para uso não gera reincidência, salientando-se que o delito em comento é punido apenas com medidas distintas da restrição de liberdade, sem que haja possibilidade

de conversão dessas medidas para prisão em caso de descumprimento, visto que a conduta de porte de substância para consumo próprio foi despenalizada pela Lei de Drogas (HC 453.437 e RE 430.105/RJ).

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência, conforme acórdãos abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (55,3 G DE MACONHA E 5,8 G DE COCAÍNA). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 63, CAPUT, DO CP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE. COMBATIDO ARESTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. 1.

Conforme disposto no decisum ora recorrido, verifica-se que o acórdão não merece reparos, porquanto as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade (HC n. 453.437/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/10/2018). 2. Consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, vale dizer, não houve abolitio criminis. Desse modo, tratando-se de conduta que